الوصول للولي بالهاتف
والتزويج بالمكالمات الهاتفية

الشيخ الدكتور

محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،

فقد كثر السؤال عن حكم تزويج المرأة مع غياب وليها الذي يمكن الوصول إليه عن طريق المكالمة الصوتية، أو المرئية، ومدى صحة عقد النكاح عن طريق المكالمات الهاتفية.

فأجبت بأن ذلك يكون ببيان المسائل التالية:

الأولى: الولي شرط في النكاح.

الثانية: التزويج عند غياب الولي من باب الرخص.

الثالثة: إذا أمكن الوصول إلى الولي فله حكم الشاهد لا الغائب.

الرابعة: صحة عقد النكاح عن طريق المكالمات الهاتفية بنوعيها.

وهذا أوان الشروع في بيان ذلك على قواعد الفقه الشافعي باختصار يناسب المقام، والله أسأل التوفيق والسداد.

المسألة الأولى:

الولي شرط في النكاح

جاء في القرآن والسنة الصحيحة الصريحة أن الولي شرط في عقد النكاح، ولا يصح العقد إلا بإذن الولي، وأنه إذا تنازع الناس في الولاية الخاصة، فالسلطان يتولى عقد النكاح بولايته العامة.

قال تعالى ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾ البقرة: ٢٣٢

ففي هذه الآية مخاطبة الأولياء ونهيهم عن عضل من في ولايتهم من النساء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى الطرفان، ولولا أن العقد مرتبط بالولي لما كان النهي متوجها إليهم، وسبب نزول الآية يبين ذلك.

فروى البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه، قال: زوّجتُ أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه"(١).

(١) رواه البخاري (رقم ٥١٣٠).

وعقد الشافعي في الأم باب (لا نكاح إلا بولي) واحتج بهذ الآية فقال(٢):" زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها، ثم أراد الزوج، وأرادت نكاحه بعد مضي عدتها، فأبى معقل وقال: زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها، لا أزوجكها أبدا، فنزل ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ يعني الأزواج النساء ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فبلغن أجلهن﴾ يعني فانقضى أجلهن يعني عدتهن ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ يعني أولياءهن ﴿أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ﴾إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن، وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا، ولا أعلم الآية تحتمل غيره، لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل، بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء، والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها، وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره، وهو لا يعضلها عن نفسه، وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف".

---

(٢) الأم (١٣/٥).

ومن السنة ما رواه الشافعي في الأم(٣) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها".

قال الشافعي:" ففي سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دلالات منها: أن للولي شركا في بضع المرأة، ولا يتم النكاح إلا به ما لم يعضلها، ثم لا نجد لشركه في بضعها معنى تمَلُّكه، وهو معنى فضل نظر بحياطة الموضع أن ينال المرأة من لا يساويها".

ومن السنة أيضا ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا:" لا نكاح إلا بولي"(٤).

وقد اختلف في وصله وإرساله، وفي الترجيح بينهما، واحتج به الشافعي فقال في الأم (٥):" وهذا وإن كان منقطعا دون النبي –صلى الله عليه وسلم– فإن أكثر أهل العلم يقول به".

---

(٣) الأم (١٧٨/٥).

(٤) رواه أبو داود (رقم ٢٠٨٥) والترمذي (رقم ١١٠١) وابن ماجه (رقم ١٨٨١).

(٥) الأم (١٨٠/٥).

قال أبو عبد الباري: وبهذا وما لم نذكره مما في معناه يتبين اشتراط الولي في النكاح، وأنه لا يصح دون إذن الولي إلا في حالات تشتثنى بدليل آخر، لمعنى صحيح في الشرع بشروطه، وهو ما سنبحثه في المسائل التالية.

المسألة الثانية:

التزويج عند غياب الولي

من باب الرخص

إذا عرفت ما تقدم في المسألة الأولى وهي وجوب الرجوع للولي في نكاح المرأة، فقد يتعذر أو يعسر إذن الولي في النكاح، وقد يكون ذلك بسبب العضل والخلاف، أو بسبب فقدان أهلية الولاية لأجل نقص أو فسق ونحوهما، أو يكون بسبب غياب الولي وسفره، فيتولى السلطان أو نائبه كالقاضي النكاح نيابة عن الولي بالولاية العامة.

قال الشافعي في الأم(٦):" وفي هذه الآية الدلالة على أن النكاح يتم برضا الولي والمنكحة والناكح، وعلى أن على الولي أن لا يعضل، فإذا كان عليه أن لا يعضل فعلى السلطان التزويج إذا عضل، لأن من منع حقا فأمر السلطان جائز عليه أن يأخذه منه، وإعطاؤه عليه، والسنة تدل على ما دل عليه القرآن، وما وصفنا من الأولياء والسلطان".

وعلى هذا المعنى دلت السنة الصحيحة، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي".

(٦) الأم (١٧٨/٥).

قال الشافعي في الأم(٧):" وفي هذا دليل على أن على السلطان إذا اشتجروا أن ينظر، فإن كان الولي عاضلا أمره بالتزويج، فإن زوج فحق أداه، وإن لم يزوج فحق منعه، وعلى السلطان أن يزوج أو يوكل وليا غيره فيزوج، والولي عاص بالعضل، لقول الله عز وجل ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، وإن ذكر شيئا نظر فيه السلطان، فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له منعها، وإن دعاها الولي إلى خير منه، وإن دعت إلى غير كفاءة لم يكن له تزويجها، والولي لا يرضى به، وإنما العضل أن تدعو إلى مثلها أو فوقها فيمتنع الولي".

وقال أيضا فيه(٨):" إذا كان الولي حاضرا فامتنع من التزويج فلا يزوجها الولي الذي يليه في القرابة، ولا يزوجها إلا السلطان الذي يجوز حكمه، فإذا رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن يسأل عن الولي، فإن كان غائبا سأل عن الخاطب، فإن رضي به أحضر أقرب الولاة بها وأهل المحرم من أهلها وقال: هل تنقمون شيئا؟ فإن ذكروه نظر فيه، فإن كان كفئا ورضيته أمرهم بتزويجه، فإن لم يفعلوا زوجه، وإن لم يأمرهم

---

(٧) الأم (٥/١٤).

(٨) الأم (٥/١٥).

وزوجه فجائز، وإن كان الولي حاضرا فامتنع من أن يزوجها من رضيت صنع ذلك به، وإن كان الولي الذي لا أقرب منه حاضرا فوكل قام وكيله مقامه، وجاز تزويجه كما يجوز إذا وكله بتزويج رجل بعينه فزوجه، أو وكله أن يزوج من رأى فزوجه كفئا ترضى المرأة به بعينه، فإن زوج غير كفء لم يجز، وكان هذا منه تعديا مردودا، كما يرد تعدي الوكلاء".

وتضمن هذا النص عن الشافعي أن الولاية لا تنتقل للأقرب إذا غاب الولي، وأن السلطان يزوجها إذا دعت إلى كفوء، وليس فيه تفريق بين غيبة طويلة وقصيرة.

وقال الجويني في نهاية المطلب(٩):" والولايةُ الحقيقية تقتضي أحكامًا على المَوْلِيِّ عليه، واستبدادًا بالتصرف للنظر، فإن لم يكن المتصرَّف له أهلًا ، لصغر أو زوال عقل، فعليه نهاية الولاية، وإن كان أهلًا، وامتنع من عليه الحق، استقلّ السلطان باقتضاء الحق قهرًا، وإن انقطع نظرُ الأهل لغيبة، فهذا محل تصرف السلطان".

(٩) نهاية المطلب (٤٧/١٢).

وقال أيضا(١٠):" وفحوى الحديث دال على أن تزويجه ليس على حقيقة الولاية؛ ولذلك يزوج بالنيابة القهرية في العضل والغَيْبة".

وفي بيان مواضع ولاية السلطان قال الجويني في نهاية(١١):" والمواضع التي يزوج فيها السلطان خمسة:

أحدها: إذا عضل الولي المناسب، أو من له ولاء إذا دعت إلى كفء فامتنعا زوجها السلطان.

والموضع الثاني: إذا غاب الأخ، وحضر العم، زوّجها السلطان.

والثالث: ألا يكون لها ولي ولا مولى، فالسلطان ولي من لا ولي له.

والرابع: أن يريد الولي أن يتزوج مولاته، وليس له مشارك في الولاية، فيزوجه السلطان.

الخامس: تزويج المجنونة البالغة إذا كان النظر في تزويجها، ولا أب لها ولا جد، ففي أحد الوجهين تزويجها إلى السلطان؛ لأنه هو الناظر العام، وليس لها قريب كامل الشفقة، ولأن السلطان يلي مالها في هذه

---

(١٠) نهاية المطلب (١٢/١٦٦).

(١١) نهاية المطلب (١٢/٤٥).

الحالة، فإذا مسّت حاجتها إليه زوّجها، بخلاف الصغيرة؛ فإنه لا حاجة بها، فتؤخر إلى حين بلوغها واستئذانها ".

وهذه الصور منها ما هو منصوص، وهو ما كان بالعضل والمشاجرة، وما عدا ذلك مقيس عليه.

ووجه تزويج السلطان إنما هو –على المعتمد في المذهب– من باب النيابة عن الولي لبقاء ولاية الولي، ولهذا لا تنتقل للأبعد، ولولا ذاك لانتقلت الولاية للأبعد.

قال في النجم الوهاج(١٢):"وتزويجه في هذه الحالة، وحالة العضل، وحالة التشاجر بطريق النيابة، لا بطريق الولاية؛ لأن الولي لم يخرج عن ولايته، وولايته ثابتة مع غيبته، بدليل أنه لو زوج في غيبته صح.

وإن كان له وكيل لم ينعزل، ويصح تزويجه في غيبته بشرطه الآتي، والذي ذكره المصنف هو المشهور، وحكى عن ابن سريج: أن الغيبة تنقل الولاية للأبعد كالجنون، وهو بعيد".

والتزويج في هذه الحالة لئلا تتضرر المرأة، ولمرعاة مصلحتها في الزواج، وألا يفوتها الكفء الراغب، وهي في المعنى كالعضل.

---

(١٢) النجم الوهاج (٩٦/٧).

قال الماوردي في الحاوي(١٣):" لأن استئذانه مع بعد الغيبة شاق؛ ولأن طول الزمان في بعد المسافة ففوت على الزوجة حقها من العقد".

وعلل إمام الحرمين في النهاية(١٤) بأن الشرع ندبنا إلى الابتدار إلى تزويج النساء من الأكفاء، وحقها واجب، وليس من حق الواجب أن يؤخر مع الطالب المستحق".

قال في النجم(١٥):" لأن الغائب ولي، والتزويج حق عليه، فإذا تعذر استيفاؤه منه قام السلطان مقامه كما لو عضل".

---

(١٣) الحاوي الكبير (١١٠/٩).

(١٤) نهاية المطلب (١٠٤/١٢).

(١٥) النجم الوهاج للدميري (٩٦/٧).

المسألة الثالثة:

إذا أمكن الوصول إلى الولي

فله حكم الشاهد لا الغائب

بنى الفقهاء جواز تزويج السلطان على تعذر الوصول إلى ولي المرأة واستيفاء الحق منه، وخشية فوات الكفء، ولإمكان الوصول للولي صور منها:

الأولى: أن يكون دون مرحلتين، لأن الغيبة في المسافة القصيرة كالإقامة، ولو كان مقيما في البلد لم يزوجها الحاكم كما قال في النجم(١٦).

الثانية: أن يكون معلوم المكان ولو كان بمرحلتين أو أكثر، كالملوك، وبه قال القاضي أبو حامد من أصحابنا، فإنه فرق بين الأكابر فاعتبر مراجعتهم، والتجار وأوساط الناس فلم يعتبره كما في النجم(١٧).

الثالثة: ما استجد من استحداث وسائل التواصل المسموعة والمرئية عبر القارات، والتي جعلت الغائب كالحاضر في المجلس، والوصول إليه أسهل ممن هو خارج المجلس، مع إمكان معرفة المتصل عليه تارة بصورته، وتارة بصوته بحضور من يعرفه، أو باختباره بالسؤال عما لا يعرفه غير الولي الحقيقي.

---

(١٦) النجم الوهاج للدميري (٩٨/٧).

(١٧) النجم الوهاج للدميري (٩٦/٧).

وإذا كان انتظاره أو الوصول إليه مع سفره دون المرحلتين مانعا من تزويج السلطان، فلأن يمتنع لإمكان الوصول إليه في ساعات ودقائق بالهاتف أولى، لأن الرخصة هنا كانت لتعذر الوصول للولي أو مشقته، وحتى لا يفوت الكفء، وكل ذلك ممنوع هنا إذا أمكن الوصول للولي عن طريق الهواتف المذكورة.

وقد علل فقهاؤنا إمكانية الوصول للولي فيما إذا كان مسجونا، فلا يزوجها السلطان، لأنه يمكنه الوصول إلى الولي، وإن كان متعذرا من جهة الولي تزويج موليته، فاعتبروا إمكان الوصول إلى الولي في سجنه، كما عللوا ذلك في غيبة الولي دون مسافة القصر، فتبين بذلك أن إمكان الوصول إلى الولي بمشقة مثل ما ذكرناه يمنع تزويج السلطان والقاضي، ومشقة الوصول إلى الولي بالهاتف أسهل من هذه الصور.

ومما يجري في هذا المعنى قول النووي في المنهاج:" والإغماء إن كان لا يدوم غالبا انتظر إفاقته، وإن كان يدوم أياما انتظر".

وفي تحرير الفتاوى للولي العراقي(١٨) أن هذا:"موافق لإطلاق "الحاوي" أن الإغماء لا ينقل للأبعد، وهو الذي حكاه الرافعي عن

(١٨) تحرير الولي العراقي (٢/٥٤٠).

"التهذيب" وغيره، وحكى عن الإمام أنه ينبغي إن كانت مدة يعتبر فيها إذن الولي الغائب، وقطع المسافة ذهابًا ورجوعًا انتظرت إفاقته، وإلا فيزوج الحاكم، ويرجع في معرفة مدته إلى أهل الخبرة، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد".

وعلة ذلك أن الرجوع للولي ممكن وإن كانت فيه بعض المشقة، وذلك بانتظاره حتى يفيق من الإغماء.

وأما عن تقدير مسافة القصر عند أصحابنا فهو من باب القياس على الأحكام المبنية عليها في العبادات، وليس فيها نص صحيح يرجع إليه، وغايته رفع الضرر عن المرأة مع تعذر استيفاء الحق على الغائب، وفوات المصلحة بانتظاره.

المسألة الرابعة:

صحة عقد النكاح عن طريق المكالمات الهاتفية بنوعيها

تمهيد

يتبين مما سبق أن المسألة مبنية على استيفاء الحقوق المرتبطة بالولي عند تعذر الوصول إليه، وأن تعذر الوصول مرده العرف والعادات، وقد تقرر في المذاهب الأربعة المتبعة أن الفتوى بتغير الزمان والأحوال، فلا يصار إلى ما في الكتب من تقدير المسافة لعدم أثرها ،كما لا يصار إلى ما في الكتب من التقديرات في النفقات لتغير الزمان والأحوال، وإنما يصار إلى ما فيها إذا تعذر الوصول إليه لعدم معرفة هاتفه، أو كونه محرما ونحوه.

قول الشافعية

قال الماوردي في الحاوي في باب السرقة وضابط الحرز(١٩):" وقد فصل الشافعي الأحراز باختلاف الأحوال على حسب زمانه وعرف أهله، وقد يتغير ذلك باختلاف الزمان وتغير العادات، فيصير ما جعله حرزا ليس بحرز، وما لم يجعله حرزا يصير حرزا؛ لأن الزمان لا يبقى على حال، وربما انتقل من صلاح إلى فساد، ومن فساد إلى صلاح؛

(١٩) الحاوي الكبير (٢٨٢/١٣).

فلذلك تتغير أحوال الأحراز لكثرتها ما يكون معتبرا مع وجود أسبابه وظهور عرفه".

وقال ابن حجر الهيتمي(٢٠) في خروج النساء للمساجد وقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء لمنعهن قال:" فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان. وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم؛ لأنهم علم الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه".

قول الحنفية

وقال ابن عابدين الحنفي في مجموعة الرسائل(٢١):" اعلم أن المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في كتب المذهب في المسائل السابقة، لم يخالفوه إلا لتغير الزمان والعرف، وعلمهم أن صاحب المذهب لو كان في زمنهم لقال بما قالوه، مما يستخرج به الحق من

---

(٢٠) الفتاوى الفقهية الكبرى (٢٠٣/١).

(٢١) رسائل ابن عابدين (١٢٦/٢).

ظالم أو يدفع دعوى متعنت ونحوه بعدم سماع دعواه أو بحبسه أو نحوه".

وقال فيه أيضا:"كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم عنه المشقة والضرر بالناس، ولخالف ذلك قوانين الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد ".

قول المالكية

وقال القرافي المالكي في الفروق(٢٢):" الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت. وتبطل معها إذا بطلت كالنقود في المعاملات والعيوب في الأعراض في البياعات ونحو ذلك فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى لحمل الثمن في البيع عند الإطلاق على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به المبيع فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن لم ترد به وبهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة على العوائد وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء

(٢٢) الفروق للقرافي (١/١٧٦-١٧٧ مع الاختصار).

لا خلاف فيه، وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين ".

قول الحنابلة

وقال ابن القيم الحنبلي في الإعلام(٢٣):" من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعْظَمَ من جناية من طَبَّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطبِّ على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضَرُّ ما على أديان الناس وأبدانهم".

(٢٣) الإعلام (٤/٤٧٠ ط. مشهور).

ومما تقدم تعلم أن المذاهب الفقهية المتبعة متفقة على أن تغير الزمان والأحوال والعادات مؤثر في الأحكام المبنية على العادات والأعراف كما هو شأن مسألتنا هذه.

إذا عرفت مما سبق أن مرد المسألة تعذر الوصول للولي، وأنها من مسائل العادات التي تتغير بتغير الأحوال، فقد يمكن الوصول للولي عن طريق الهاتف مع بعد مسافته أسهل من الوصول إليه وهو في القرية التي فيها موليته، والنظر بعد ذلك في صحة تزويجه بالهاتف، والنظر في أمرين:

أولهما: جواز توكيله لغيره، فيقوم وكيله بتزويج المرأة، وهذا التوكيل صحيح كالتوكيل بالكتابة، إذ لا يشترط في الوكالة القبول مطلقا على الأصح، لأن التوكيل إباحة ورفع حجر؛ فأشبه إباحة الطعام، فيمكن للولي توكيل غيره ولو لم يحضر مجلس الاتصال كما هي قاعدة الوكالة.

ثانيهما: أن يقوم هو بالتزويج، ويتم القبول في مجلس الاتصال، وهو مبني على صحة العقود في الهواتف، واعتبار المجلس واحدا ما دام الاتصال قائما، وإنما يلزم معرفة الولي بحيث تمكن الشهادة عليه، وذلك ممكن برؤية صورته أو سماع صوته بشهادة من يعرف صوته.

اعتراض وجوابه

فإن قيل: نفى الشافعية اعتبار سماع الصوت من مسافة بعيدة لم تجر العادة على السماع منها، وجعلوه كلا كلام، وهذا ينطبق على الهاتف.

قال الهيتمي والرملي في شروط صيغة البيع:" وأن يكون تكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة، وإن لم يسمعه الآخر، وإلا لم يصح، وإن حملته الريح إليه".

قال الشرواني في حاشيته على التحفة:" قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح، وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه، ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة"، وتبعه العبادي أيضا في حاشيته على التحفة(٢٤).

وفي حاشية الجمل على منهج الطلاب(٢٥):" فإن كان بحيث لا يسمعه من بقربه لم يصح، وإن سمعه صاحبه بواسطة ريح حملته إليه، أو كان حديد السمع، لأنه كلا لفظ كما علمت، وقد يتوقف فيه اهـ.

---

(٢٤) التحفة (٤/٢٢٥) والنهاية (٣/٣٨٢).

(٢٥) منهج الطلاب (٣/١٣).

قال شيخنا الحفني: والظاهر أنه لا وقفة، لأن هذا اللفظ غير معتد به، فلا عبرة بسماعه له اهـ".

والجواب أن قوله (يسمعه من بقربه عادة) يدل على أن المرجع في ذلك العادة، وأن ما كان خلاف المعتاد لا عبرة به، وقد جرت العادة المتواترة بسماع البعيد عن طريق الهواتف، وصار البعيد مكانا كالقريب بالهاتف، بل صارت رؤيته عادة جارية عن طريق هذه الهواتف من غير كلفة مالية، فيدخل فيما جرت العادة بسماع صوته فيه، وقد تقدم أن هذه المسألة مما تتغير فيه الفتوى بتغير الأحوال.

ومن هذا الباب في اعتبار العادة قول السبكي في فتاويه(٢٦):" فلو أخبرنا مخبر أنه رأى شخصا بعيدا عنه في مسافة يوم مثلا، وسمعه يقر بحق، وشهد عليه به، لم يقبل خبره ولا شهادته بذلك، ولا نرتب عليها حكما، وإن كان ذلك ممكنا في العقل، لكنه مستحيل في العادة".

---

(٢٦) فتاوى السبكي (١/ ٢١٠).

فجعل مدار الحكم على العادة، فلو جرت العادة على رؤية البعيد باستخدام الآلات الحديثة كما هو شأن مسألتنا هذه تغيرات العادة، وقبلت هذه الشهادة.

وأما الشهادة عليه فتصح في الصورتين:

أما صورة رؤيته ومشاهدته يوكل أو يُوجب العقد فظاهرة لا إشكال فيها، وليس من شرط الشاهد معرفته السابقة بالولي، وهي أولى الصورتين ما أمكن.

وأما سماع كلامه: فيشترط أن يكون عارفا لصوته بحيث يميزه من غيره، وقد بحث فقهاؤنا في باب الشهادة هذه المسألة، وفي الروضة للنووي(٢٧) أن المشهود عليه ثلاثة أقسام:

الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الإبصار، وهو ما يشهد فيه بالاستفاضة كالنكاح والملك والنسب.

الثاني: ما يكفي فيه الإبصار، وهو الأفعال كالزنى، والشرب، والغصب، والإتلاف، والولادة، والرضاع، قال:" فلا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير".

---

(٢٧) روضة الطالبين (٢٥٩/١١).

الثالث: ما يحتاج إليهما كالأقوال، فلا بد من سماعها ومشاهدة قائلها، وذلك كالنكاح والطلاق والبيع، وجميع العقود، والفسوخ، والإقرار بها".

وأورد عليه الإسنوي في المهمات(٢٨) ما يعلم ببقية الحواس كالطعوم والروائح والحرارة وضدها.

إذا علمت ذلك فالذي يعنينا في هذه المسألة هو القسم الثالث، وما اشترطه النووي هنا، هو الذي ذكره في المنهاج(٢٩) فقال:" والأقوال كعقد يشترط سمعها، وإبصار قائلها، ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح".

وههنا تنبيهات:

الأول: أشار بقوله "على الصحيح" إلى خلاف ضعيف عنده.

وذكر الأذرعي في القوت(٣٠) الاختلاف في الشهادة على من ألفه وعرف صوته ضرورة، وقال:" قال أبو نصر البندنيجي في " المعتمد":

---

(٢٨) المهمات للأسنوي (٣٥٦/٩).

(٢٩) منهاج الطالبين (٤٤٤/٣ ط. الحداد).

(٣٠) قوت المحتاج للأذرعي (٦٩٤/١١).

واختار بعض أصحابنا قبول شهادته عليه، وأشار بذلك إلى ابن الصباغ فإنه أبداه لنفسه، قال: لأنه يقين، وذكره العمراني عنه وسكت عليه".

وذكر أنه نقله شريح الروياني وجها عن رواية جده أبي العباس الروياني، وحكى عن المزني وابن المنذر وخلائق من أهل العلم من خارج: قبول الشهادة اعتمادا على الصوت، ينبغي أنه لو شهد بإقرار زوجته بشيء في حال خلوتها، أو أبيه أو أمه أو ابنه والحالة هذه بأن قال: سمعته منه في خلوة ... ونحن نقطع بأنه صادق في قوله: أقرّ ابني عندي البارحة في جنح الليل ونحن خاليان أنه قتل زيدا الفلاني عمدا عدوانا، أو أنه زنى، ونحو ذلك مع ما هو عليه من شدة المحبة والشفقة، فرد شهادته المذكورة ونحوها جمود على غير مجمد، تقبل شهادته فيما يشهد به بالاستفاضة على الصحيح".

قال أبو عبد الباري: وأصح القولين دليلا، وأولاهما بالاعتبار صحة الشهادة عليه، لحديث ابن عباس: أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي – صلى الله عليه وسلم – وتقع فيه فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي – صلى الله عليه وسلم – وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ

عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم –، فجمع الناس، فقال: "أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام" فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها، فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم–:" ألا اشهدوا أن دمها هدر". رواه أبو داود والنسائي(٣١) بسند صحيح.

وجه الدلالة: أن الأعمى سمع صوتها، ولم يشتبه عليه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك في الدماء التي شدد الشرع فيها، فما دونها من الأحكام أولى بالقبول.

الثاني: استثناء صورة الأعمى إنما هي لإفادتها العلم بالمشهود عليه، وذلك أن المقصود من الشهادة البناء على العلم واليقين ما أمكن،

---

(٣١) رواه أبو داود (رقم ٤٣٦١) والنسائي (رقم ٤٠٧٠).

لكن من الحقوق ما لا يحصل اليقين فيه، فأقيم الظن المؤكد فيه مقام اليقين، وجوزت الشهادة بناء على ذلك الظن كما قال في الروضة(٣٢).

الثالث: ويؤيد ذلك تجويز الشافعي شهادة المختبئ مطلقا، ففي المعرفة للبيهقي(٣٣):" أشار الشافعي في حكاية بعض أصحابه في شهادة المختبئ إلى قولين: إما ألا يجيز؛ لأنه جلس غير مجلس العدول، وبسط الكلام فيه، ثم قال: وهذا مذهب شريح.

وإما أن يجيز الشهادة عليه، لأن عمر أجاز شهادة الذين رصدوا رجلا زنى، ولكن لم يتموا أربعة، قال: وهذا أشبه القولين"(٣٤).

وبه قال غير واحد من الأصحاب منهم الماوردي في الحاوي والروياني في البحر(٣٥) وغيرهما، وحكى البندنيجي عن الأصحاب ذلك في رجلين دخلا بيتا لا ثالث لهما، فعقدا عقدا، ورجل بالباب يسمعهما، أو دخل رجل بيتا ليس فيه غيره فأقرّ بشيء، ورجل بالباب يسمعه.

---

(٣٢) روضة الطالبين (٢٥٩/١١).

(٣٣) المعرفة للبيهقي (٣٤٥/١٤).

(٣٤) ونحوه في السنن الكبرى له (٤٢٣/١٠) والصغرى له أيضا (١٨٧/٤).

(٣٥) الحاوي (٢٢٢/١٧) والبحر (٣٣٦/١٤).

رابعا: ويؤيده أيضا صحة الشهادة على الاستفاضة والشهرة على النسب والنكاح والملك، والمتاع، وعلى عين المرأة، وهذا كله شهادة على علم كما قال الشافعي في الأم(٣٦)، فثبت بهذا أن السماع يكفي إذا أفاد العلم بالقائل بمن يعرفه، أو الشهود عليه، أو بالاستفاضة والتواتر، وكل ذلك قول ليس فيه رؤية المشهود عليه.

خامسا: ويؤيد ذلك ما ذكروه في الشهادة على المنتقبة، ففي منهاج النووي(٣٧):" ولا يصح تحمُّل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها، فإن عرفها بعينها، أو باسم ونسب جاز".

فأجاز الاكتفاء بمعرفتها بالعين أو الاسم والنسب عن رؤية وجهها عند سماع كلاهما، وهو نص الشافعي في الأم فإنه قال فيه(٣٨):" وكذلك يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له أخبار من يصدق بأنها فلانة، ويراها مرة بعد مرة، وهذا كله شهادة بعلم كما وصفت".

---

(٣٦) الأم (٩٦/٧).

(٣٧) منهاج الطالبين (٤٤٤/٣ ط. الحداد).

(٣٨) الأم (٩٦/٧).

وعلة المنع من الشهادة على الصوت هي كما قال الشافعي في الأم([٣٩]) من قبل أن الصوت يشبه الصوت، لكن يمكن الخروج من هذا بأن يكون يعرفه بعينه أو بالاسم والنسب كما في المنتقبة، أو باختباره بما لا يعرفه غيره من أخبار المجلس وحضوره، أو باختبار الصوت وفحصه عند الشك، كما يجري ذلك بآلة فحص الأصوات، والتأكد من مطابقتها لصاحب الصوت، وغير ذلك من الطرق المستحدثة.

وإذا كان الولي شرطا في النكاح بالنص، والوصول إليه والتحقق من صوته ممكنا، فلا يجوز ترك النص وتجاوزه لهذه العلة التي يمكن حلها بما ذكرنا.

خاتمة

هذا التقرير يفيد أيضا أم ما عرف بزواج الخطيفة لا يصح، وذلك لوجهين:

---

(٣٩) الأم (٩٦/٧).

الأول: أن الوصول للولي ممكن بالهاتف غالبا، فإذا لزم في الغائب المسافر ولو لبلد بعيد، فوجوبه في مق من اعتدي على ولايته، وخطفت موليته من باب أولى، فيكون هذا التقريرا سدا لهذا الافتئات على أولياء المرأة.

الثاني: أن التزويج عند غياب تعذر الوصول للولي من باب الرخص، ولا تناط بالمعصية عند أصحابنا، وهذه نتف من أقوالهم في ذلك:

١) ففي فتح العزيز للرافعي (١/١٤٦ ط. العلمية):"إذا استنجي بشئ محترم من مطعوم وغيره عصى، وهل يجزئه ذلك عن الفرض، فيه وجهان: أحدهما: نعم، لأن المقصود قلع النجاسة وقد حصل، فصار كالاستنجاء باليمين.

وأظهرهما: أنه لا يجزئه، لأن الاقتصار على الأحجار من قبيل الرخص، والرخص لا تناط بالمعاصي".

٢) وقال في صفة صلاة الخوف (٢/٣٤٠ ط. العلمية):" تجوز هذه الصلاة في كل ما ليس بمعصية من أنواع القتال دون ما هو معصية، لأن الرخص لا تناط بالمعاصى".

٣) وفي نهاية المطلب للجويني في صلاة الخوف (٢/٥٩٧):"وإن حرمت الهزيمة، لم يجز لهم أن يصلوا صلاة الخوف؛ فإنهم متعرضون في الهزيمة المحرمة لسخط الله، والرخص لا تناط بالمعاصي عندنا".

٤) وفي منهاج الطالبين في صلاة المسافر:" ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة، فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية، فلا ترخص في الأصح".

٥) وقال الزركشي في المنثور في القواعد (٢/١٦٧):" الرخص لا تناط بالمعاصي. ومن ثم العاصي بسفره لا يترخص "بالفطر والقصر" والجمع، ولا يأكل الميتة ولا يمسح مدة " المسافر " قطعا، ولا مدة المقيم في الأصح، ولا تسقط عنه الجمعة بسفره ولا يباح له التطوع راكبا وماشيا، لغير القبلة".

٦) وقال السبكي في " الأشباه والنظائر" (١/١٣٥):" (قاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي)، وضرب لها أمثلة.

إذا تقرر ذلك فالسفر بالمرأة دون إذن وليها، وبدون محرم معها سفر معصية، فلا تتعلق به رخصة التزويج من غير وليها بدون إذنه، لأن

الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا بيِّنٌ لا خفاء فيه، فلا يصح تزويج الخطيفة على مذهب السادة الشافعية.

تم الانتهاء من تحرير هذا الجواب عصر الثلاثاء، ثالث شعبان سنة ١٤٤٥هـ والموافق للثالث عشر من فبراير لعام ٢٠٢٤م بمدينة نيروبي – كبرى مدن كينيا – شرق إفريقيا.

د. محمود محمد الشبلي

أبو عبد الباري الصومالي